

1500655-44.2020.8.26.0438

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANO SANTOS DE LIMA

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 20/11/2022

... subsidiário, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a desclassificação da conduta em razão de ser usuário de drogas.

É o breve relatório. Decido.

Afasto a preliminar de nulidade de provas decorrentes do ingresso no domicílio do acusado Higor. Em infrações permanentes, como no caso de tráfico de drogas, a situação de flagrância se protraí enquanto não cessar a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

3ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis-SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500655-44.2020.8.26.0438 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500655-44.2020.8.26.0438

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2125136/2020 - 01º D.P. PENAPOLIS, 7416276 - 01º D.P. PENAPOLIS, 352/20/310 - 01º

D.P. PENAPOLIS, 2125136 - 01º D.P. PENAPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HIGOR GABRIEL HERRERO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANO SANTOS DE LIMA

Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em desfavor de HIGOR GABRIEL HERRERO, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Emerge da denúncia (fls. 108/109):

Consta dos incluídos autos de inquérito policial que, no dia 24 de março de 2020, por volta das 15:30 horas, na Rua Gonçalves Lêdo, Jardim Paula Pereira, nº. 882, nesta cidade e comarca de Penápolis/SP, HIGOR GABRIEL HERRERO, qualificado a fls. 100/101, guardava e trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de entrega e fornecimento a consumo de terceiros, 06 (seis) porções de cocaína, na apresentação conhecida por crack, com peso de 4,6

gramas do entorpecente, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09/10 e laudo químico-toxicológico de fls. 16/21.

Determinada a notificação do denunciado (fl. 111), esta realizou-se à fl. 136.

A defesa prévia foi apresentada às fls. 148/158.

A denúncia foi recebida em 03 de maio de 2022, oportunidade em que se determinou a realização da audiência de instrução e julgamento (fls. 165/166).

Durante a instrução, colheu-se o depoimento de duas testemunhas e, ao final, foi realizado o interrogatório do acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão manifestada na denúncia, a fim de se condenar o denunciado como incurso no tipo penal mencionado na inicial acusatória.

A Defesa, a seu turno, suscitou a preliminar de nulidade em razão da ausência de autorização judicial para ingresso domiciliar. No mérito, postulou a absolvição do acusado por ausência de provas e, em caráter subsidiário, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a desclassificação da conduta em razão de ser usuário de drogas.

É o breve relatório. Decido.

Afasto a preliminar de nulidade de provas decorrentes do ingresso no domicílio do acusado Higor. Em infrações permanentes, como no caso de tráfico de drogas, a situação de flagrância se protraí enquanto não cessar a permanência (art. 303 do Código de Processo Penal). Ademais, o entendimento dominante acerca do tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que "é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017). No caso, sequer se pode dizer que houve ingresso forçado no domicílio do acusado Higor, haja vista que sua esposa, Karen, estava na residência e autorizou a entrada dos policiais. Não obstante, os policiais já conheciam o acusado dos meios policiais pelo comércio ilegal de entorpecentes, não sendo a primeira vez que o abordavam. Assim, estando evidente a situação de flagrante, inclusive com a localização da droga na frente da residência, não haveria necessidade de ordem judicial para incursão no local.

Não há preliminares ou prejudiciais ao mérito. Por outro lado, encontram-se presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Em virtude disso, avanço diretamente à análise do mérito.

A materialidade do crime imputado ao réu restou devidamente comprovada pelos seguintes elementos juntados aos autos: boletim de ocorrência policial (fls. 4/6), auto de exibição/apreensão (fls. 9/10), laudos definitivos de exame químico-toxicológico, indicando que foi detectada a presença das substâncias cocaína nos materiais analisados (fls. 16/18 e 19/21), laudos de objetos apreendidos (fls. 22/24 e 25/27) e depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto na instrução processual.

A substância em questão encontra-se presente na relação de substância de uso proscriito no Brasil, conforme o disposto na Portaria 344/98 do SVS/MS e suas atualizações.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado, muito embora este tenha negado a prática da traficância em seu interrogatório judicial, afirmando que a droga se destinava ao uso próprio.

A testemunha Juliano Ferreira Lopes, policial militar, disse que estava em patrulhamento de rotina; que adentrou à rua em que Higor morava; que Higor estava conversando com desconhecido; que foi se aproximar; que os dois correram para o lado da residência, transpondo o muro dos fundos; que, na frente da residência, havia 5 porções de crack e R\$ 10,00 reais jogados ao chão; que o outro policial avistou no quarto de Higor um prato sobre a cama com uma porção de crack fracionada; que entrou em contato com Karen, que estava grávida; que, no local, havia também balança de precisão e sacola plástica; que já abordou Higor por quatro vezes anteriores; que a equipe era composta por dois policiais; que, ao avistar a

droga, não saiu em busca de Higor, pois precisava aprender a droga; que a esposa de Higor já estava dentro da residência.

A testemunha Bruno Prado de Oliveira, policial militar, afirmou que estava em patrulhamento de rotina; que adentrou à rua em que Higor morava; que Higor é conhecido dos meios policiais por tráfico e outros delitos; que Higor estava conversando com desconhecido; que foi se aproximar; que os dois correram para o lado da residência, transpondo o muro da residência; que Higor jogou algo ao chão; que adentrou o imóvel e avistou prato em cima da cama com porção de "crack"; que Karen autorizou a entrada dos policiais no imóvel; que foi apreendido o entorpecente que estava no prato; que havia mais cinco porções de "crack", que foram jogadas ao chão por Higor; e que Karen disse que a droga não lhe pertencia e que pertencia a Higor.

Em seu interrogatório judicial, o réu Higor Gabriel Herrero negou a prática delitativa. Disse que tem 22 anos; que é amásio de Karen; que possui um filho com Karen; que trabalhava como carpinteiro e como ajudante de pintor; que usava "crack"; que estava na residência; que estava usando droga; que a quantia que estava no prato era do interrogando; que acabou o isqueiro, que estava em cima do guarda-roupa; que saiu para comprar um novo isqueiro; que, ao sair, os policiais passaram pelo interrogando; que os policiais ficaram cochichando; que o interrogando se questionou por qual motivo os policiais estavam ali; que o policial Juliano costuma "forjar" as situações; que a residência do interrogado não tem corredor ou fundos; que não correu; que não retornou para residência; que ficou sabendo que a esposa do interrogado estava dentro da casa; que não compareceu; que não estava na frente da casa; que não estava com outra pessoa; que estava sozinho; que as cinco porções não eram do interrogando; que o cachimbo e o isqueiro não foram apreendidos; que a balança não era do interrogando; que o interrogando morava apenas com a esposa; a droga que era do interrogando pesava no máximo duas gramas; que não tinha plástico picado no local; que a droga comprou com pessoa de nome Arthur, conhecido como "Arturzinho"; que comprou R\$ 100,00; que não sabe a quantidade da droga; que não tinha balança; que tinha comprado a droga no mesmo dia; que usaria no mesmo dia a droga que era de sua propriedade; que as cinco porções e a balança de precisão foram forjadas pela polícia; que o policial Juliano já forjou o interrogando em outras oportunidades.

A negativa do acusado encontra-se isolada do conjunto probatório, indo de encontro às alegações dos policiais militares, os quais, em relato uníssono, afirmaram que o acusado, ao avistá-los, jogou o entorpecente ao chão e empreendeu fuga. Os policiais não conseguiram alcançá-lo, porém, visualizaram, no interior da residência, um prato com mais uma porção de droga fracionada

Logo em seguida, foram localizadas, na frente da residência, cinco porções do entorpecente e uma nota de R\$10,00 dispensadas pelo acusado antes da fuga. Além disso, dentro do imóvel os policiais apreenderam mais uma porção da droga e alguns petrechos utilizados para a traficância (balança de precisão e saco plástico picado).

A entrada na residência do acusado foi permitida por sua esposa, Karen, que afirmou aos policiais que a droga ali localizada era de Higor.

Saliente-se que os depoimentos prestados pelos policiais foram coerentes e harmônicos com os demais subsídios de convicção existentes nos autos - especialmente com o laudo de constatação da substância entorpecente - e não há nenhum indicativo a colocar em xeque a idoneidade das informações prestadas.

Em verdade, o exercício da função de agente da lei não pode, por si só, tornar suspeita a versão dos fatos apresentados, pois seria um contrassenso que o Estado incumbisse tais pessoas da função repressiva e lhes negasse crédito quando relatam suas diligências.

Além disso, nada foi demonstrado a desprestigiar as palavras dos policiais militares que efetuaram a diligência, inexistindo quaisquer elementos ao menos indicativos de interesse dos milicianos em incriminar injustamente o réu.

Diante desse cenário, a autoria em relação ao denunciado resta, portanto, de todo comprovada nos autos, uma vez que a droga foi efetivamente encontrada em poder do acusado, restando evidente a ciência e a conduta de trazer consigo e de guardar a

droga.

No tocante à tipicidade do crime de tráfico de drogas em si, dentre outras modalidades descritas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, incrimina-se as condutas de guardar e de trazer consigo, bastando que a finalidade do agente não seja para consumo próprio.

E, no caso em apreço, afastam-se teses de absolvição por ausência de provas e de desclassificação para o delito de porte de entorpecente para consumo próprio. Infere-se do auto de exibição e apreensão e dos laudos de constatação acostados aos autos que foram apreendidos em poder do réu 0,8 gramas de cocaína, na forma de "crack", em cinco porções embaladas e prontas para a venda, além de 10,61 gramas de cocaína, na forma de "crack".

De fato, não se trata de uma quantidade tão elevada de entorpecente. Contudo, aliada às demais circunstâncias em que ocorreu o flagrante, especialmente a forma de acondicionamento da substância e a apreensão conjunta da quantia de R\$ 10,00 (dez reais) em espécie, de balança de precisão e de embalagem plástica rasgada, a quantidade não é ínfima o suficiente para tornar crível a versão de que o acusado é mero usuário.

Ora, é certo que o usuário de drogas não adquire os entorpecentes diariamente, em pequenas quantidades, mas compra um montante determinado, prevendo que durará por pelo menos alguns dias. Todavia, no caso concreto, diante das mencionadas peculiaridades, não há dúvidas de que as substâncias estavam prontas para o comércio e para tal se destinava.

Por isso, não se mostra cabível acolher a alegação de que todo o entorpecente apreendido destinar-se-ia apenas ao consumo pessoal.

Dessa forma, devidamente evidenciadas a materialidade e a autoria delitiva, assim como a subsunção dos fatos à figura típica do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, não há de se acolher as teses defensivas de absolvição, por insuficiência de provas, tampouco a de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Assim, presente o elemento subjetivo do tipo, restando evidenciada a conduta dolosa do acusado, agindo com a vontade e consciência necessárias. A natureza e quantidade de drogas apreendida e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida não tinha outra destinação que não a revenda a terceiros.

A conduta típica é antijurídica, não havendo qualquer causa justificante para a realização delas. De acordo com a teoria da ratio cognoscendi, segundo a qual a tipicidade da conduta induz a antijuridicidade, a prova acerca da existência de uma justificativa fica a cargo da defesa, ônus do qual o réu não se desincumbiu.

Em termos de culpabilidade, o acusado é imputável, já que maior de 18 anos de idade, além de não se enquadrar nas situações do artigo 26, caput e parágrafo, do Código Penal; tinha consciência da ilicitude de sua conduta; e lhe era exigível comportamento de acordo com o direito, eis que não foi suscitada nenhuma hipótese de inexigibilidade de conduta diversa pela defesa.

Dessa feita, a condenação do acusado nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 é medida que se impõe.

Em observância ao artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República, bem como ao artigo 68 do Código Penal, passo a individualizar a pena segundo o método trifásico elaborado por Nélson Hungria.

Na primeira fase, verifica-se que a culpabilidade, entendida como juízo de reprovabilidade do comportamento do agente, não extrapolou a normalidade do tipo. O réu é tecnicamente primário (fls. 127/130), não possuindo maus antecedentes. Não há elementos acostados aos autos para permitir a aferição da personalidade do réu e a sua conduta social. O motivo do crime não refoge à normalidade nesse tipo de ilícito. As circunstâncias e as consequências são normais ao tipo penal. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu, até porque o crime é vago, ou seja, não possui sujeito passivo determinado. Passando à análise específica das circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, verifica-se que a natureza e a quantidade da droga já foram sopesadas para fins de subsunção dos fatos ao delito de tráfico de entorpecentes, razão pela qual deixo de valorá-las novamente, evitando-se bis in idem. Portanto, ausentes circunstâncias judiciais

desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes de pena, devendo-se destacar que, nos termos do Enunciado nº 630 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio".

Na terceira fase, inexistem causas de aumento a serem valoradas. De outro lado, ante a primariedade do acusado, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de comprovação de que o acusado se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, restam preenchidos os requisitos do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, devendo-se incidir a causa de diminuição de pena. Cabe destacar que a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado não pode ser afastada com fundamento em investigações ou processos criminais em andamento. Desse modo, reconhecida a causa de diminuição e não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, reduzo a pena no patamar máximo previsto, 2/3 (dois terços), para fixá-la em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a qual torno definitiva.

Ante a ausência de dados concretos a respeito da situação econômica do réu, arbitro o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, em 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, a ser devidamente atualizado no momento da execução, pelos índices de correção monetária adotados por este Tribunal (artigo 43 da Lei nº 11.343/2006 c/c artigo 49, §§1º e 2º, do Código Penal).

À vista do quantum de pena aplicado e da primariedade do acusado, o regime para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal.

A pena privativa de liberdade é inferior a quatro anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, além de estarem presentes os demais requisitos exigidos pelo artigo 44 do Código Penal. Assim sendo, cabível a substituição da pena privativa de liberdade pelas seguintes penas restritivas de direitos: a) prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo atualmente vigente (R\$ 1.212,00), em favor de entidade a ser especificada pelo juízo da execução; e, b) prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, em entidade a ser especificada pelo juízo da execução, conforme as aptidões do condenado, cujas horas deverão ser fixadas de modo a não prejudicar sua jornada normal de trabalho.

Incabível a suspensão condicional da pena em razão da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Deixo de fixar indenização mínima à vítima (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal), pois o crime é vago, não havendo vítima definida.

Por todas as razões expostas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o réu HIGOR GABRIEL HERRERO pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com a causa de diminuição prevista no § 4º da mesma lei, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, estes fixados em 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, com substituição da pena privativa de liberdade pelas seguintes penas restritivas de direitos: a) prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo atualmente vigente (R\$ 1.212,00), em favor de entidade a ser especificada pelo juízo da execução; e, b) prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, em entidade a ser especificada pelo juízo da execução, conforme as aptidões do condenado, cujas horas deverão ser fixadas de modo a não prejudicar sua jornada normal de trabalho.

Admito que o réu recorra em liberdade, uma vez que, no decorrer do processo, não houve alteração fática a ensejar a prisão cautelar.

Condeno o sentenciado ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 804 do CPP. Entretanto, considerando que o(a) sentenciado(a) foi assistido por advogado nomeado nos termos do convênio com a Defensoria Pública, associado às

circunstâncias do processo, tudo indica sua insuficiência de recursos para fazer frente a esse débito, motivo pelo qual desde logo lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça e determino a suspensão das condenações pecuniárias contidas neste parágrafo, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil.

Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPESP. Elabore-se a competente certidão de honorários advocatícios.

Declaro o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União, na forma do art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006, os quais deverão ser revertidos diretamente ao Funad.

Transitada em julgado da presente condenação:

A) destruam-se as amostras guardadas para contraprova, certificando nos autos, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006;

B) coloquem-se os bens e valores perdidos (fls. 15/16) à disposição da União (Funad);

C) expeça-se guia definitiva de cumprimento da pena;

D) intime-se o réu para pagar a pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias, a teor do artigo 50 do Código Penal;

E) comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III, da Constituição da República; e

F) Lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Penápolis, 20 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA